



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Registro: 2015.0000027670

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Carta Testemunhável nº 0010963-26.2012.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é testemunhante MARESSA CAROLINE ALONSO PEREIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é testemunhado JUÍZO DA COMARCA.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO à presente Carta Testemunhável, interposta por MARESSA CAROLINE ALONSO PEREIRA, representada por PATRÍCIA REGINA ALONSO, mantendo a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos. V.U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR MECCHI MORALES (Presidente sem voto), TOLOZA NETO E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.

São Paulo, 27 de janeiro de 2015

LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

VOTO Nº 19346

CARTA TESTEMUNHÁVEL Nº 0010963-26.2012.8.26.0009

TESTEMUNHANTE: MARESSA CAROLINE ALONSO PEREIRA

(CRIANÇA REPRESENTADA POR PATRÍCIA REGINA ALONSO)

**TESTEMUNHADO..: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
FORO REGIONAL DE VILA PRUDENTE
COMARCA DE SÃO PAULO**

(Juiz de Direito de 1ª Instância: doutor **ALEXANDRE MUÑOZ**)

Adoto como Relatório o bem lançado pelo d. Procurador de Justiça, doutor FRANCISCO CEMBRANELLI, nos seguintes termos:

*“... Trata-se de Carta Testemunhável interposta por **MARESSA CAROLINE ALONSO PEREIRA**, representada por sua genitora, **PATRÍCIA REGINA ALONSO**, e por meio de seu defensor, inconformada com a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito do Foro Regional de Vila Prudente, Comarca de São Paulo, o qual não recebeu Recurso em Sentido Estrito que objetiva reformar anterior decisão que manteve arquivamento de Inquérito Policial em razão da inexistência de novas provas.*

Em suas Razões recursais, a defesa pretende, em apertada síntese, a reforma da decisão com o consequente recebimento do Recurso em Sentido Estrito interposto, uma vez que este buscava a reabertura das investigações que visavam apurar eventual prática de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

*delito de estupro por parte de MARCOS DO NASCIMENTO PEREIRA, figurando como vítima a sua filha, **MARESSA CAROLINE ALONSO PEREIRA**, fato que teria acontecido em diversas datas, até o dia 03 de outubro de 2010, na Rua Ibitirama, 1530, ap. 94, Vila Prudente, Comarca da Capital.*

O recurso foi contrariado pelo Promotor de Justiça oficiante, pugnando pela manutenção da r. decisão atacada pela defesa, pois o 'Recurso previsto no art. 581, do Código de Processo Penal, não se presta ao inconformismo das decisões de arquivamento de inquérito policial ou daquelas que mantêm seu arquivamento'.

Reexaminando a decisão, o ilustre Magistrado a manteve, uma vez que o rol do art. 581, do Código de Processo Penal, é taxativo e não prevê a possibilidade de recurso em casos de arquivamento de Inquérito Policial ...” (fls. 405/406).

Com a remessa dos autos à esta Instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer pelo não provimento do recurso (fls. 405/407).

A Testemunhante apresentou novas petições, requerendo a juntada de artigo retirado da internet (fls. 409/412) e cópias de petições apresentadas na ação de divórcio e de alienação parental, ambas em trâmite perante a 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Vila Prudente, Comarca de São Paulo (fls. 414/438).

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

1. Primeiramente, manifesto o equívoco da Testemunhante, visto que não cabe Recurso em Sentido Estrito contra r. decisão que determinou o arquivamento de Inquérito Policial.

Como bem ressaltado pelo d. Magistrado de Primeira Instância, o rol do art. 581, do Código de Processo Penal, é taxativo, não contemplando a pretensão da Testemunhante, sendo correto o não recebimento do Recurso em Sentido Estrito, que deve ser mantido.

2. Outrossim, sendo o **MINISTÉRIO PÚBLICO** o titular exclusivo da ação penal pública (art. 129, I, da Constituição Federal) e, tendo requerido o arquivamento da *delatio criminis* (instaurado para apuração do crime de estupro de vulnerável), nada mais pode ser feito.

Insiste-se, preciso o art. 129, I, da Constituição Federal, ao estabelecer que “... *são funções institucionais do Ministério Público: ... promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei ...*”, com isso, em se tratando de caso de crime dessa natureza, não tem a “vítima” legitimidade para questionar o arquivamento do inquérito policial.

Bem ou mal, e aqui não cabe análise, o dono da ação penal, o **MINISTÉRIO PÚBLICO**, disse de seu desinteresse no prosseguimento da persecução penal, ante a ausência de requisitos mínimos (indícios de materialidade e autoria) para oferecimento da denúncia, no que foi atendido pelo d. Magistrado, o que não legitima a “vítima” buscar dar-lhe seguimento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Somente na hipótese prevista no art. 18, do Código de Processo Penal, é que o Inquérito Policial poderá ser desarquivado.

Portanto, correta a r. decisão do d. Magistrado de Primeira Instância quando consigna:

“... O não recebimento do Recurso em Sentido Estrito está em consonância com o art. 581, do Código de Processo Penal, que contém um rol taxativo das hipóteses nas quais é cabível a interposição do referido recurso, sendo que, dentre tais hipóteses, não se encontra presente o arquivamento de Inquérito Policial. Falta, portanto, interesse recursal no presente caso.

Além disso, pretende a representante da vítima a interposição de referido recurso, mas esta não é parte na causa, carecendo de legitimidade para recorrer ...” (fls. 402).

Vale consignar, ainda, que na Apelação Criminal nº 0007171-64.2012.8.26.0009, interposta pela Testemunhante, julgada nesta Sessão, foi proferido acórdão nos seguintes termos:

“VOTO Nº 19264

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007171-64.2012.8.26.0009

APELANTE: MARESSA CAROLINE ALONSO PEREIRA

(CRIANÇA REPRESENTADA POR PATRÍCIA REGINA ALONSO)

APELADOS: MARCOS DO NASCIMENTO PEREIRA
MINISTÉRIO PÚBLICO

ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
FORO REGIONAL DE VILA PRUDENTE
COMARCA DE SÃO PAULO

(Juiz de Direito de 1ª Instância: doutor ALEXANDRE MUÑOZ)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

MARESSA CAROLINE ALONSO PEREIRA, criança representada por sua genitora **PATRÍCIA REGINA ALONSO**, interpôs a presente Apelação (fls. 876/877), em face da r. decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher do Foro Regional de Vila Prudente, Comarca de São Paulo, nos autos de Processo Cautelar de Medidas Protetivas nº 0007171-64.2012.8.26.0009, Controle nº 1751/12, que extinguiu a ação cautelar de medidas protetivas, sem julgamento do mérito, ante o arquivamento do Inquérito Policial instaurado para apuração de crime de estupro de vulnerável atribuído ao seu genitor, **MARCOS DO NASCIMENTO PEREIRA** (fls. 872).

*Em suas Razões, MARESSA pretende, em síntese, que a r. decisão de fls. 872 seja cassada ou declarada nula, porque: a)- o d. Magistrado não considerou a presente Medida Protetiva como ação penal, ao consignar às fls. 352/354 que '... não se trata de assistente de acusação, figura que somente na ação penal ...', pois trata-se de uma ação com finalidade de proteger, tutelar um bem maior ameaçado, não se tratando de ação cautelar, não existindo ação principal a ser proposta; b)- não houve indeferimento da medida, como aduzido na r. decisão, mas sim deferimento às fls. 37, proibindo o agressor de '... aproximar-se da vítima, familiares dela e testemunhas a uma distância de 300 metros, bem como de, com eles, manter qualquer forma de contato ...'; c)- o Inquérito Policial foi arquivado prematuramente, pois o d. Magistrado apenas fez uma análise perfunctória dos fatos, '... mais preocupado em esvaziar sua mesa ante a pressão estabelecida pelo C.N.J., do que proteger a menor do grave risco que passa a correr, se o agressor se aproximar dela ...'; d)- houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada 'vista' dos autos ao seu Advogado para que apresentasse quesitos ou se pronunciasse sobre o Laudo Pericial ofertado, conforme consta de fls. 868, '... contudo, a Patrona do Apelado apresentou quesitos que mesmo sem o deferimento e aceitação do MM. Juízo 'a quo', foram respondidos pelas peritas nomeadas, ressaltando, desde logo, uma diferença de tratamento, o que torna a r. decisão tendenciosa e, por si só, anulável ...'; e)- a r. decisão refere-se a **PATRÍCIA REGINA ALONSO PEREIRA** como beneficiária das Medidas Protetivas, quando na verdade seria a Apelante, sendo que '... não poderia haver um erro mais gritante que esse, o que demonstra que sequer foi lido os autos na sua inteireza ...'; f)- a r. decisão de*



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

fls. 872 não revogou a liminar concedida, sendo de rigor sua manutenção até final julgamento e trânsito em julgado da presente ação; g)- contesta o teor do Laudo Psicossocial, que é contraditório, pois conclui erroneamente pela inexistência de infração, mas consigna às fls. 610 que '... opino contrariamente ao restabelecimento do contato de MARESSA com o genitor MARCOS ...'; também contesta as 'experts', que foram parciais, pois afirmaram que a progenitora da Apelante estava mais preocupada com a pensão alimentícia de que com o crime perpetrado contra ela, patrocinando "alienação parental" da Apelante em relação ao Apelado, não se atendo ao foco da perícia; e realça o que entende favorável, sendo que o Apelado confessou que dormia na apertada cama da Apelante – fls. 589 que, por seu turno, disse que ele 'fediu', o que seria o resultado de sua masturbação, assim como o Apelado afirmou que entrou no banheiro enquanto a vítima tomava banho, devendo eventual dúvida favorecê-la; h)- deve ser observado o princípio da 'pessoalidade do Magistrado', para a perfeita avaliação dos fatos; e, por fim, i)- o Apelado é doente mental, com séria patologia sexual, devendo ser submetido a tratamento psiquiátrico (fls. 878/885).

MARCOS DO NASCIMENTO PEREIRA apresentou Contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pela declaração de incompetência deste Eg. Tribunal de Justiça; afastamento das preliminares aduzidas pela Apelante; e, no mérito, pelo não provimento do recurso, e que '... sejam as sanções previstas na Lei de Alienação Parental aplicadas ... seja a guarda da menor invertida para o Recorrido, com como seja compelida a Sra. PATRÍCIA ao pagamento de multa a ser quantificada por este Tribunal ...' (fls. 898/909).

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofertou Contrarrazões, pugnando pelo afastamento dos pedidos preliminares; aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, acolhendo o presente como Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo não provimento do recurso (fls. 927/931).

Com a remessa dos autos à esta Instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer, opinando, preliminarmente, pela conversão do julgamento em diligência, para que o Juízo de Origem cumpra o quanto determinado no art. 589, do Código de Processo Penal e, no mérito, pelo não provimento do recurso (fls. 948/949).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Foi determinado o retorno dos autos à origem para o cumprimento do disposto no artigo precitado, ante a probabilidade de eventual incidência do princípio da fungibilidade (fls. 950).

A Apelante peticionou informando a interposição de recurso em face da r. decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial, bem como requereu a juntada de artigo retirado da 'internet' (fls. 953/956).

Em juízo de retratação, o d. Magistrado de Primeira Instância manteve sua decisão por seus próprios fundamentos (fls. 958).

A Apelante apresentou novas petições insurgindo-se contra a r. decisão, em juízo de retratação, que manteve a decisão anterior, reiterando as Razões de Apelação; bem como requerendo a produção de novo Laudo Psicossocial pelos peritos da UNICAMP (fls. 963/971) e a juntada de cópias de petições apresentadas na ação de divórcio e de alienação parental, ambas em trâmite perante a 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Vila Prudente, Comarca de São Paulo.

É o relatório.

1. DAS PRELIMINARES

a)- Primeiramente, insta consignar a competência desta Egrégia Terceira Câmara de Direito Criminal para o julgamento do presente recurso, pois as medidas protetivas estampadas na Lei nº 11.340/06, deferidas como medidas cautelares em Inquéritos Policiais, como no caso, tem natureza penal.

b)- Quanto ao recurso cabível, observo que a Apelação foi tempestiva e corretamente interposta, nos termos do art. 593, II, considerando que a r. decisão teve força de definitiva, pondo fim ao presente processo cautelar, sendo proferida por Juiz singular, não havendo previsão nos incisos do art. 581, ambos do Código de Processo Penal.

c)- O pedido de reconhecimento de cerceamento de defesa formulado pela Apelante (pois não teria sido intimada para apresentação de quesitos ou para que se pronunciasse sobre o



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Laudo Pericial ofertado, '... contudo, a Patrona do Apelado apresentou quesitos que mesmo sem o deferimento e aceitação do MM. Juízo 'a quo', foram respondidos pelas peritas nomeadas, ressaltando, desde logo, uma diferença de tratamento, o que torna a r. decisão tendenciosa e, por si só, anulável ...'), deveria ter sido eventualmente apresentado nos autos principais, e não na presente ação cautelar que tem natureza diversa, somente versando sobre as medidas protetivas em favor da Apelante.

d)- Também não há nulidade na r. decisão por ter citado que a beneficiada da medida protetiva seria a mãe da Apelante, PATRÍCIA, ou que houve cessação da proteção, pois tratam-se de meros erros materiais que não comprometem o mérito da decisão, que foi devidamente fundamentada.

e)- Ao contrário do que defende a Apelante, a r. decisão que deferiu as medidas protetivas foi tacitamente revogada quando o d. Magistrado determinou a extinção do presente feito, não sendo o caso de sua renovação nesta Instância, ante a ausência de seus requisitos, que serão analisados com o mérito.

f)- Quanto ao alegado arquivamento prematuro do Inquérito Policial, a contestação do conteúdo do Laudo Pericial, o pedido de realização de novo estudo psicossocial e a suposta doença mental que acomete o Apelado, vejo que tais matérias não podem ser tratadas no âmbito desta cautelar de Medidas Protetivas, pois são objetos próprios da ação principal (Inquérito Policial).

g)- O princípio da identidade física do Juiz não foi vulnerado, pois o § 2º, do art. 399, do Código de Processo Penal, reza que '... o Juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença ...', sendo que o feito em comento trata-se de ação cautelar, e a principal sequer chegou ao oferecimento da denúncia, não havendo, por isso, produção de provas em Juízo para que se pudesse eventualmente questionar citado princípio.

h)- O pedido realizado pelo Apelado em Contrarrazões para que '... sejam as sanções previstas na Lei de Alienação Parental aplicadas ... requerendo seja a guarda da menor invertida para o Recorrido, bem como seja compelida a Sra. PATRÍCIA ao pagamento de multa a ser quantificada por este Tribunal ...', é estranho ao presente feito, tratando-se de matéria extrapenal, devendo ser rechaçada.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

2. DO MÉRITO

Referente ao mérito, constato que os recursos, assim como as ações, estão sujeitos a condições genéricas, como a possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade ou legitimação.

Sendo o MINISTÉRIO PÚBLICO o titular exclusivo da ação penal pública (art. 129, I, da Constituição Federal) e, tendo requerido o arquivamento da delatio criminis (processo principal instaurado para apuração do crime de estupro de vulnerável), nada mais pode ser feito quanto ao presente processo cautelar de Medidas Protetivas, vez que perdeu seu objeto, eis que não teria confirmada nenhuma situação de risco para a vítima, restando ausentes, portanto, o 'fumus boni iuris' e o 'periculum in mora' que justificaram o anterior deferimento das medidas protetivas, afastando a necessidade de sua manutenção.

Insiste-se, preciso o art. 129, I, da Constituição Federal, ao estabelecer que '... são funções institucionais do Ministério Público: ... promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei ...', com isso, em se tratando de caso de crime dessa natureza, não tem a "vítima" legitimidade para questionar o arquivamento do inquérito policial e, da mesma forma, de medida cautelar que, em face dessa providência, justificou a extinção do processo, sem exame do mérito.

Assim, carece a Apelante de interesse e, com isso, de legitimidade para interposição de qualquer recurso.

Bem ou mal, e aqui não cabe análise, o dono da ação penal (principal), o MINISTÉRIO PÚBLICO, disse de seu desinteresse no prosseguimento da persecução penal, ante a ausência de requisitos mínimos (indícios de materialidade e autoria) para oferecimento da denúncia, no que foi atendido pelo d. Magistrado, acarretando, por consequência, a extinção da ação cautelar de Medidas Protetivas, o que não legitima a Apelante buscar dar-lhe seguimento.

Somente na hipótese prevista no art. 18, do Código de Processo Penal, é que o Inquérito Policial poderá ser desarquivado e, neste caso, se presentes os requisitos legais, as medidas protetivas poderão ser renovadas.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Portanto, correta a r. decisão do d. Magistrado de Primeira Instância quando consigna:

'... O inquérito instaurado para análise dos fatos, no entanto, foi arquivado, pois não se logrou obter elementos mínimos da efetiva prática do crime. E, não havendo elementos a indicar a ocorrência de violência doméstica, em sentido amplo, ausente o 'fumus boni juris' a justificar o prosseguimento da ação cautelar.

Da mesma forma, não vislumbro a presença do 'periculum in mora', na medida em que ... não houve novo relato de reiteração da referida prática pelo averiguado por parte da vítima.

Os elementos acima mencionados, quais sejam, o 'fumus boni juris' e o 'periculum in mora' são os próprios objetos da cautelar. Sem objeto, carece a requerente de interesse de agir. A extinção do processo, sem exame do mérito, portanto, é de rigor ..." (fls. 872).

Vale consignar, ainda, que na Carta Testemunhável nº 0010963-26.2012.8.26.0009, interposta pela Apelante, julgada nesta Sessão, foi proferido acórdão nos seguintes termos:

bv
'...'

Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente Apelação, interposta por MARESSA CAROLINE ALONSO PEREIRA, representada por sua genitora PATRÍCIA REGINA ALONSO, ante a ilegitimidade de parte, determinando o arquivamento dos autos ...".

Ante todo o exposto, **NEGO PROVIMENTO** à presente
 Carta Testemunhável, interposta por **MARESSA CAROLINE**



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

ALONSO PEREIRA, representada por **PATRÍCIA REGINA ALONSO**, mantendo a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
 Relator
 (Assinatura Eletrônica)